

<제1장 노동법 총론 제4절 근로기준법상 근로자>

I. 의의[근기법 제2조 제1항 제1호]

- 근로기준법 제2조 제1항 제1호는 근로자를 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 자라고 정의한다. 이 정의는 근로기준법을 포함한 개별적 근로관계법의 적용 대상을 규정하는 가장 기본적인 개념이며, 근로자가 아닌 자에게는 근로기준법상의 보호가 적용되지 않는다.

II. 취지

- 근로기준법상 근로자 개념의 취지는 사용자의 지휘·감독 아래 종속적인 관계에서 근로를 제공하고 그 대가로 임금을 받아 생활하는 경제적 약자를 보호하는 데 있다. 근로기준법은 대등한 당사자 간의 계약을 전제로 하지 않고, 사용자와 근로자의 실질적인 불평등 관계를 개선하여 근로 조건의 최저 기준을 보장함으로써 근로자의 인간다운 생활을 보장하고자 하는 목적을 가진다.

III. 근로기준법상 근로자의 개념

1. 직업의 종류 무관

- 근로자의 개념은 육체 노동자인지 정신 노동자인지, 정규직인지 비정규직인지, 상시직인지 임시직인지 등 직업의 종류나 고용 형태와 상관없이 실질적인 근로 관계에 따라 판단된다. 이는 형식적인 계약 명칭에 구애받지 않고 실질에 따라 보호를 확대하려는 취지이다.

2. 임금을 목적으로

- 임금을 목적으로 한다는 것은 근로의 대가로 반대 급부(임금)를 받는 것을 의미한다. 임금은 근로의 대가로서 주된 목적이어야 하며, 순수하게 자원 봉사나 직업 훈련 등을 주된 목적으로 하는 경우에는 근로자로 인정되지 않을 수 있다.

3. 사업 또는 사업장에서 근로를 제공하는 자

- 사업 또는 사업장은 노동력이 현실적으로 제공되고 사용자가 존재하는 장소적 범위를 의미하며, 근로를 제공한다는 것은 단순한 노무의 제공을 넘어 사용자의 지휘·감독 아래 종속적인 관계에서 노무를 제공하는 것을 의미한다.

IV. 대법원의 근로자성 판단기준

1. 사용종속관계의 인정

- 근로기준법상 근로자에 해당하는지 여부는 계약의 형식이 민법상 고용계약인지 도급계약인지에 관계없이, 그 실질에 있어 사용자에게 노무를 제공하고 그 대가로 임금을 받는 사용종속관계가 존재하는지에 따라 판단된다.

2. 판단기준★

(1) 업무 내용의 사용자에게 의한 지정 여부

- 업무 내용을 사용자가 구체적으로 지정하고 수행 방법에 대해 상당한 지휘·감독을 하는지 여부가 핵심 기준이다.

(2) 근무 시간과 장소의 구속성

- 근무 시간과 장소가 사용자에게 의해 구속되는지 여부이다. 구속성이 높을수록 종속성이 인정된다.

(3) 대체 근로 가능성

- 근로자가 스스로 제3자를 고용하여 업무를 대신하게 할 수 있는지 여부이다. 사용자의 승낙이 필요한 경우 종속성이 인정된다.

(4) 독자적인 사업자로서의 이익 창출 및 손해 부담 여부

- 근로자가 독자적인 사업자로서 자신의 계산으로 이익을 창출하거나 손실을 감수하는지 여부이다. 독자적인 이익 창출 및 손실 부담이 없을수록 종속성이 인정된다.

(5) 비품, 원자재, 작업 장소 등의 사용자 제공 여부

- 근로를 수행하는 데 필요한 설비나 비품 등을 사용자가 제공하는지 여부이다. 사용자가 설비나 비품 등을 제공하는 경우 종속성이 인정된다.

(6) 기본급이나 고정급의 존재 여부와 임금의 성격

- 기본급이나 고정급이 정해져 있고, 보수가 근로 자체의 대가인지 여부이다. 임금의 성격이 근로자체의 대가인 경우 종속성이 인정된다.

(7) 근로 제공 관계의 계속성과 사용자에게 대한 전속성

- 근로 제공이 계속적이고 특정 사용자에게 전속되어 다른 업무의 겸직이 제한되는지 여부이다. 계속적이고 전속적인 업무를 수행하는 경우 종속성이 인정된다.

(8) 사회보장제도 적용 및 근로소득세 원천징수 여부

- 4대 보험 등 사회보장제도에 근로자로서 가입되어 있는지와 근로소득세를 원천징수하는지 여부이다. 사회보장제도에 가입되었거나 근로소득세를 원천징수하는 경우 종속성이 인정된다. 다만, 사용자가 경제적 우위를 이용하여 임의로 정할 소지가 있어 보조적 요소로 참작된다.

3. 검토

- 판례는 위의 판단 기준들을 종합적으로 고려하되, 특히 사용자가 업무 내용을 지휘·감독하고 근무 시간 및 장소를 구속하는 등 노무를 제공하는 사람이 사업자로서의 독립성 없이 사용자에게 실질적으로 종속되어 있는지 여부를 가장 중요하게 판단한다.

V. 임원의 근로자성 인정 여부

1. 사용종속관계의 인정

- 회사의 임원(이사, 감사 등)은 원칙적으로 회사와의 관계가 위임 계약에 따른 사무 처리에 해당하며, 근로기준법상 근로자로 인정되지 않는다. 이는 임원이 회사 경영에 참여하고 위임받은 사무를 처리하는 지위에 있기 때문이다.

2. 위임사무의 처리

- 임원이라 하더라도 회사 경영의 실질적인 의사결정에 참여하지 않고, 이사라는 형식적인 직함만 가졌을 뿐 일반 근로자와 동일하게 사용자의 구체적인 지휘·감독을 받으며 정해진 근로 시간과 장소에서 노무를 제공하고 그 대가로 보수를 받는다면, 예외적으로 근로기준법상 근로자로 인정될 수 있다.

VI. 특수형태근로종사자의 근로자성(2022.06.10 삭제)

1. 의의[산재법 제125조 제1항]

- 특수형태근로종사자는 계약 형식이 위임이나 도급이더라도 실질적으로는 종속성을 가지고 노무를 제공하며 주로 하나의 사업에 전속되어 생계를 유지하는 사람들을 말한다. 근로기준법상 근로자에는 해당하지 않는 경우가 많지만, 경제적 약자로서 보호가 필요하다는 사회적 공감대에 따라 산업재

해보상보험법 제125조 제1항 등에서 산재보험의 적용을 특례적으로 받는다.

2. 산재법상 특례의 적용

- 산업재해보상보험법은 근로기준법상 근로자가 아님에도 불구하고 업무상 재해로부터 보호할 필요성이 있는 특수형태근로종사자의 직종을 법률로 명시하고, 이들에게도 산재보험을 적용하는 특례 규정을 두고 있다. 이는 근로기준법의 좁은 근로자 개념이 보장하지 못하는 영역을 사회보장법을 통해 보완하는 조치이다.

Ⅵ. 불법체류외국인의 근로자성

- 불법체류외국인이라 하더라도 근로기준법상 근로자에 해당하는지 여부는 외국인의 국적이나 취업의 적법성과는 관계없이, 실질적인 사용종속관계가 있는지에 따라 판단된다. 판례는 불법체류를 이유로 근로자에게 근로기준법상의 권리를 부정할 수 없다고 보아, 불법체류외국인도 근로기준법상 근로자로 인정받을 수 있으며, 임금 및 퇴직금 등의 권리를 보호받을 수 있다는 입장이다.

Ⅶ. 소사장(도급제사원)의 근로자성

- 소사장(도급제사원)은 외형상 특정 업무를 도급받아 자율적으로 처리하는 형태를 띠지만, 그 실질에 있어 사용자로부터 지휘·감독을 받고, 자신의 계산이 아닌 회사의 계산으로 업무를 수행하며, 독자적인 사업 경영의 능력이나 위험 부담이 없는 경우가 있다. 소사장의 근로자성 역시 대법원의 사용종속성 판단 기준에 따라 개별적이고 종합적으로 판단되며, 실질적으로 사용종속관계가 인정되면 근로기준법상 근로자로 보호받을 수 있다.

Ⅷ. 결론

- 근로기준법상 근로자는 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사용자에게 근로를 제공하는 경제적 약자를 보호하기 위한 개념이다. 대법원은 계약의 형식이 아닌 실질적인 사용종속관계를 핵심 판단 기준으로 삼아 근로자성을 종합적으로 판단한다. 임원은 원칙적으로 위임 관계이나 예외적으로 근로자성이 인정될 수 있고, 특수형태근로종사자 및 불법체류외국인도 실질적인 종속성이 인정되면 근로기준법상 근로자로 보호받으며, 특수형태근로종사자는 산재보험의 특례를 통해 사회보장적 보호를 추가적으로 받는다. 이처럼 근로자성 판단은 노동법의 적용 범위를 결정하는 가장 중요하고 실무적인 쟁점이다.